

1500252-95.2021.8.26.0614

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos  
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Magistrado: ÉNDERSON DANILO SANTOS DE VASCONCELOS  
Comarca: Tambaú  
Foro: Foro de Tambaú  
Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... permanência e estabilidade na associação para o tráfico dos réus em relação a outros agentes. Logo, a imputação quanto ao crime de associação para o tráfico não merece prosperar.

Neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tambaú

Foro de Tambaú

Vara Única

Rua Campos Salles, 345, Tambaú-SP - cep 13710-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500252-95.2021.8.26.0614 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500252-95.2021.8.26.0614

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2201197/2021 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 19248438 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 78/21/212 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 2201197 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHAEL FELIPE DE MORAIS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ÉNDERSON DANILO SANTOS DE VASCONCELOS

Vistos.

MICHAEL FELIPE DE MORAIS, ROBERTO TULIO RODRIGUES FERREIRA, GUSTAVO NATAN DONIZETTI VIEIRA e MARCOS ADRIANO VICK, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática do crime previsto nos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 26/07/2021, por volta das 17h30min, em via pública, esquina entre a Rua Maria Rita do Prado Silva e a Rua Monsenhor José C. de Carvalho, neste município, associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06. Consta, ainda, que, no mesmo

dia e horário, enquanto associados, vendiam e tinham em depósito, visando a entrega ao consumo de terceiros: cocaína, em 46 eppendorfs, com peso bruto de 50,5g e maconha, em 14 porções, com peso de 45,7g, todas embaladas e prontas para comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

No dia dos fatos, Marcos estava recolhendo drogas na vegetação para vendê-las em via pública, momento que foi abordado pela polícia. No local, foram apreendidas as substâncias supra, embalados à comercialização. Ato contínuo, Michael foi até o local de vegetação para buscar mais drogas para comercialização, momento que também foi abordado pelos policiais. Em sua posse, foi encontrado um celular e R\$ 30,00, frutos da mercancia ilícita. Em seguida, os denunciados Roberto e Gustavo estavam no ponto de tráfico, quando também foram abordados pelos policiais e detidos em flagrante. Com ROBERTO foi encontrado R\$ 200,00 e um celular, já com Gustavo, nada foi encontrado. Entretanto, no local e tempo mencionados, Gustavo também foi visto entrando drogas a um usuário que estava de bicicleta, não restando dúvidas da prática ilícita.

Habilitados nos autos, os réus foram intimados (fls. 300).

Defesa preliminar apresentada pelos réus (fls. 301/303, 306/308, 318/322 e 331/335).

Denúncia recebida às fls. 347/348.

Os réus foram citados (fls. 433/436).

Acusação e defesa apresentaram suas alegações finais por debates orais.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência parcial da pretensão punitiva, pugnano pela condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Quanto a associação pugna pelo reconhecimento apenas em relação aos réus Michael e Roberto Túlio.

A defesa de Gustavo Natan Donizetti Vieira aponta inexistir prova da traficância. Defende também inexistir vínculo permanente e duradouro que justifique a imputação pela prática do crime de associação para o tráfico. Pugna pela absolvição do réu e subsidiariamente pela aplicação da pena no mínimo legal.

A defesa de Marcos Adriano Vick reconhece a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, negando a prática do crime de associação. Aponta inexistir provas da prática do crime de associação para o tráfico. Pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

Michael Felipe de Moraes, em suas alegações finais, aponta haver contrariedade nos depoimentos policiais. Defende que o réu é usuário de entorpecentes, tendo ido até o local para adquiri-los, quando foi abordado. Aponta inexistir estabilidade e permanência que autorizem a prática do crime de associação para o tráfico.

Roberto Túlio Rodrigues Pereira, em suas alegações finais, defende que nenhuma conduta ilícita foi imputada a Roberto Túlio, diz que nenhum dos verbos nucleares dos crimes que lhe foram imputados foi praticado. Defende que a prisão ocorreu apenas em virtude do acesso ilícito ao celular do réu. Defende ser usuário de drogas. Pretende a absolvição do réu. Aponta inexistir prova da prática do crime de associação para o tráfico.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

#### DAS NULIDADES

Argumenta Roberto Túlio que sua prisão decorreu do acesso indevido de seu aparelho celular, sem autorização judicial, sendo esta a razão de sua prisão, com isso, defende a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

O direito à prova, como todo e qualquer direito fundamental, não tem natureza absoluta. Está sujeito a limitações porque coexiste com outros direitos igualmente protegidos pelo ordenamento jurídico. Não por outro motivo, dispõe a Constituição Federal que "são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos" (art. 5º, LVI).

Na lição de Renato Brasileiro de Lima, "aos olhos do leigo, soa desarrazoado permitir-se a absolvição de um culpado pelo fato de a prova contra ele produzida

ter sido obtida por meios ilícitos. Para ele, os fins justificam os meios. Ora, não podemos perder de vista, jamais, que vivemos em um Estado Democrático de Direito, e que neste a descoberta da verdade não pode ser feita a qualquer preço. Mesmo que em prejuízo da apuração da verdade, no prol do ideal maior de um processo justo, condizente com o respeito aos direitos e garantias fundamentais da pessoa humana, não se pode admitir a utilização em um processo de provas obtidas por meios ilícitos. A eficiência processual, compreendida como a funcionalidade dos mecanismos processuais tendentes a alcançar a finalidade do processo, que é a apuração dos fatos e das responsabilidades, não pode prescindir do respeito aos direitos e garantias fundamentais, sob pena de deslegitimação do próprio sistema punitivo” (Manual de Processo Penal, 2020, Juspodivm, pg. 684).

Ainda, como assevera o autor, seria contraditório em um processo criminal, destinado à apuração da prática de um ilícito penal, se o próprio Estado se valesse de métodos violadores de direitos, ou seja, ele próprio se utilizar de ilícitos penais.

Interessante e pertinente comentário faz Paulo de Sousa Mendes quanto ao assunto: “de resto, a proibição de utilização (=valorização) das provas proibidas afigura-se como a melhor maneira de o legislador prevenir a tentação de obtenção das provas a qualquer preço, por parte das instâncias formais de controle social. É como se o legislador anunciasse aos virtuais prevaricadores: – não sucumbais ao canto da sereia da obtenção das provas a qualquer preço, porquanto isso vos custaria a inutilização absoluta dos meios de prova ilicitamente obtidos, nem sequer se podendo repetir essas provas por outros meios! Por exemplo, se invadistes o domicílio do suspeito sem a devida autorização judicial e nesse local encontrastes a arma do crime, então é como se tivésseis destruído essa prova material” (MENDES, Paulo de Sousa. Lições de Direito Processual Penal. Coimbra: Almedina, 2014, p. 182-183).

Na mesma linha, já se pronunciou o Min. Celso de Mello: , “a Constituição da República, em norma revestida de conteúdo vedatório (CF, art. 5º, LVI), desautoriza, por incompatível com os postulados que regem uma sociedade fundada em bases democráticas (CF, art. 1º), qualquer prova cuja obtenção, pelo Poder Público, derive de transgressão a cláusulas de ordem constitucional, repelindo, por isso mesmo, quaisquer elementos probatórios que resultem de violação do direito material (ou, até mesmo, do direito processual), não prevalecendo, em consequência, no ordenamento normativo brasileiro, em matéria de atividade probatória, a fórmula autoritária do “male captum, bene retentum”. A expressão male captum, bene retentum significa “mal colhida, mas bem conservada” (STF, 2ª Turma, RHC 90.376/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Dje-018 17/05/2007).

A sanção prevista na Constituição para a prova reconhecida ilícita é a sua inadmissibilidade processual (CF, art. 5º, LVI). Mas não somente as provas obtidas por meios ilícitos são inadmissíveis. Reconhece-se que as provas ilícitas por derivação são os meios probatórios que, não obstante produzidos, validamente, em momento posterior, encontram-se afetados pelo vício da ilicitude originária, que a eles se transmite, contaminando-os, por efeito de repercussão causal.

A teoria utilizada para tal reconhecimento é denominada de frutos da árvore envenenada, e, com a entrada em vigor da Lei nº 11.609/08, esta teoria passou a constar expressamente do Código de Processo Penal. Segundo o art. 157, §1º, do CPP, “são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras” (gn).

No caso dos autos não é possível dizer que a prova que conduziu a prisão e denúncia do acusado Roberto Túlio decorreu do acesso ao seu celular, ao contrário, os depoimentos policiais aponta que houve monitoramento do ponto de drogas e que visualizou os réus, inclusive Roberto, na entrega da droga aos usuários, apontando que Roberto teria ido ao terreno em busca da droga em duas oportunidades.

Logo, evidencia-se que a prisão em flagrante não se relaciona ao conteúdo do celular, mas a campanha realizada e a visualização dos réus, inclusive Roberto, realizado a traficância. Tampouco a acusação pela prática do crime de tráfico de drogas tem como pressuposto o conteúdo do aparelho telefônico.

Ademais, não é possível dizer, pelo depoimento dos policiais, que o acesso ao celular ocorreu no momento da abordagem, trata-se de informação em passant, servindo para ressaltar que houve análise dos celulares dos acusados em momento posterior.

Portanto, além de não haver prova de que os celulares foram acessados no momento da abordagem policial, não há que se falar em nulidade da prova, mormente porquanto a acusação e demais atos instrutórios tenham fonte independente de eventual conteúdo do celular, nos termos do art. 157, §1º, do CPP. Por fim, quanto ao conteúdo extraído, houve autorização judicial.

Assim, rejeito a preliminar.

## DO MÉRITO

Trata-se de ação penal proposta pela Representante do Ministério Público, onde imputa aos réus a prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

## DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES e DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

O topo do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar"

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objetivo material é a droga, o jurídico é a saúde pública. O artigo 35, do mesmo diploma legal, possui a seguinte redação:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei.

Para a prática deste tipo legal, basta que haja associação de duas pessoas, contudo, exige-se que este ajuste não seja eventual, mas ao contrário, que hajam elementos que denotem a permanência e estabilidade.

## DA PROVA

Há nos autos auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência (fls. 76/79), auto de exibição e apreensão (fls. 80/81), auto de constatação preliminar (fls. 83), laudo pericial (fls. 204/218, 219/234, 239/292, 393/425 e 472/474) e prova oral produzida.

A testemunha Welther Vaz Martins, Policial Civil, disse que recebeu denúncias de tráfico. Monitorando o ponto de droga percebeu intenso movimentação. Destacou que os réus entregavam drogas aos usuários, revezando-se. Disse que percebeu que os réus iam até outro local supostamente retirar a droga. Disse que posicionaram outra equipe que ficou supervisionando o terreno baldio onde a droga estaria escondida. O depoente percebeu que a droga era retirada do terreno baldio. Disse que após algumas vezes, surpreenderam Marcos no momento em que se abaixava para retirar a droga do local. Disse que com ele havia cocaína, maconha e dinheiro. Conta que posteriormente Michel se dirigiu ao mesmo local, sendo também abordado. Disse que a outra equipe abordou Roberto e Gustavo que estavam no ponto de venda de droga. Disse que os celulares de Roberto e Michel havia troca de mensagem a respeito de

tráfico de droga. Afirma que havia mensagem de facção criminosa determinando que mudassem o chip de celular. Aduz que na primeira campana os quatro estavam juntos revezando a entrega de droga aos drogaditos. Disse que a campana durou cerca de 20 a 30 minutos com movimentação intensa. Esclarece que então acompanharam os réus até o local em que a droga estava escondida. Disse que viu intensa movimentação, pelo menos seis ou sete pessoas. Disse que viu os quatro reus se revezando na venda da droga. Comenta que soube que há dois donos do ponto de droga. Aponta que o terreno baldio dista 1 quarteirão do ponto de venda. Informa que Marcos foi o primeiro a ser abordado. Disse que a abordagem ocorreu no meio da tarde. Estava de 30 a 40 metros de distância dos locais. Aponta que não abordou os usuários para evitar dificuldade na investigação. Disse que a abordagem entre Marcos e Michael ocorreu em cerca de cinco minutos. Assevera que Michael foi abordado antes de chegar no local em que a droga foi localizada. Viu o Michael indo ao terreno ao menos duas vezes. Aponta que receberam denúncias deste ponto de droga específico, que não dava conta de nomes. Conta que não havia investigação específica em relação a nenhum dos réus. Disse que a abordagem ocorreu no ponto de venda de drogas.

A testemunha Evaldo Armando Antoniali, Policial Civil, disse que recebeu denúncia de tráfico de drogas no local dos fatos. Disse que se direcionaram com duas equipes, realizando campana. Disse que ficou em uma esquina, próximo do local em que a droga era comercializada. Disse que todos os réus realizavam contato com os usuários, recebendo algo e saindo. Disse que os réus se dirigiam a uma mata próxima de uma escola, local em que a droga estava escondida. Disse que Marcos foi abordado após ir pela segunda vez à mata. Disse que Michael estava indo em direção a mata, tendo comunicado a segunda equipe que fez a abordagem. Disse que eles alternavam na venda da droga. Disse que Gustavo e Roberto também foram abordados. Disse que nada foi encontrado com estes. Disse que no conteúdo do celular de Marcos e Michael havia informações de transação de drogas. Disse que no celular de Roberto havia mensagem de membro de facção criminosa determinando que trocasse o chip do celular. Disse que foram encontradas 46 porções de cocaína no local e 12 de maconha. Disse que os quatro foram visualizados realizando a comercialização. Aponta que Michael e Roberto foram até o terreno em duas oportunidades. Disse que todos também se direcionavam rumo ao terreno. Disse que permaneceram aproximadamente 25 a 30 minutos. Disse que no local o tráfico é intenso. Disse que todos se dirigiam ao terreno a pé, mas Michael chegou a ir de bicicleta. Disse que não abordaram os usuários para evitar prejuízo a investigação. Disse que optaram abordar Michael antes do local onde a droga estava por opção. Não conhecia os réus. Disse que não estavam investigando os acusados. Disse que a denúncia era a respeito de indivíduos no ponto de drogas. Disse que estava de 30 a 40 metros do local de campana. Disse que cerca de seis ou sete pessoas adquiriram as drogas.

A testemunha Samuel de Moraes, genitor de Michael, disse que ele é usuário de maconha. Disse que nunca recebeu usuário em sua residência. Disse que o réu não vendia droga em sua residência. Disse que Michael fazia bico. Disse que havia um vídeo de um policial dando uma gravata no réu Michael e derrubando-o de bicicleta. A testemunha Lucas Mateus Ramos Garcia, ouvido como informante, disse Michael é usuário de maconha. Disse que fazia bico. Disse que tem um vídeo do Michael recebendo a abordagem policial.

O Réu Michael Felipe De Moraes disse que havia saído de casa para comprar droga. Disse que não viu o rapaz que iria comprar, saiu de bicicleta. Disse que retornou ao local, quando foi abordado de forma grosseira e violenta por um policial. Disse que a informação é que estaria havendo uma investigação por roubo. Disse que a população filmou. Disse que iria comprar a droga do Marcos. Disse que não estava com os demais réus. Disse que não trabalha com comércio. Disse que as vezes usava droga com outro usuário. Disse que outros usuários entravam em contato para saber de droga. Disse que passou perto do terreno. Disse que foi abordado depois de ir ao terreno. Afirma que estava há mais de duzentos metros do terreno. Afirma que depois de colocado na viatura sofreu pressões e agressões dos policiais. Disse que foi intimidado na delegacia.

O Réu Roberto Tulio Rodrigues Ferreira disse que a acusação não é verdadeira. Disse que estava indo ao mercado. Disse que conhece o Gustavo, ficou do lado de fora do

mercado conversando com Gustavo. Disse que foram colocado na viatura e levado no mato onde estavam os outros réus. Disse que as mensagens no celular eram relacionados a aquisição de droga por ele. Disse que ele que pedia as drogas pelas mensagens. Disse que chá é maconha, óleo é cocaína e balinha é maconha.

O Réu Gustavo Natan Donizetti Vieira disse que tinha acabado de chegar do serviço, tendo ido até a mercearia. Disse que ficou na porta da mercearia. Disse que o Roberto estava no local. Aduz que ficou conversando com ele, quando chegaram dois carros e fizeram a abordagem. Conta que não tinha nada. Disse que conhecia Marcos e Michael.

O Réu Marcos Adriano Vick disse que estava vendendo drogas sozinho. Disse que foi abordado no mato e que Michael comprou droga consigo.

#### DO FATO TÍPICO, ILÍCITO E CULPÁVEL

A materialidade delitiva restou comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência (fls. 7679), auto de exibição e apreensão (fls. 80/81), auto de constatação preliminar (fls. 83), laudo pericial (fls. 204/218, 219/234 239/292, 393/425 e 472/474) e prova oral produzida.

A autoria restou comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1) e pela prova oral produzida em audiência.

A dinâmica dos fatos restou suficientemente esclarecida pelos policiais civis que estavam em duas equipes e permaneceram em campana em viaturas descaracterizadas por cerca de trinta minutos a cerca de 30 metros do local dos fatos.

Ambos os policiais ouvidos, de forma uníssona e coerente, contaram que em monitoramento ao ponto de venda de droga identificaram intensa movimentação de usuários, com a comercialização da droga realizada pelos réus. Segundo os relatos, os réus entregavam a droga e se revezavam. Há inclusive informação de que possivelmente o ponto de venda de droga pertenceria a duas pessoas distintas, o que justificaria o revezamento.

Ainda segundo o preciso relato dos policiais, os réus se revezavam ao ir buscar a droga em um terreno baldio, o que ocorreu por mais de uma vez. Marcos teria sido abordado ao se abaixar para retirar a droga e Michael enquanto se dirigia ao mesmo local. Ainda segundo os depoimentos, os quatro réus se revezavam na venda.

Como fica evidente, todos os réus participaram da prática do tráfico, alternando suas posições, ora vendendo, ora indo buscar a droga.

Aos quatro agentes fora imputada a prática das mesmas condutas, vender e ter em depósito as substâncias entorpecentes ilícitas. Segundo os relatos, estes se revezavam na prática das ações, o que não afasta o cometimento do delito.

Após acompanhar a empreitada, os policiais lograram êxito em encontrar a droga no terreno baldio, prendendo Marcos e Michael, este antes de chegar ao terreno, embora tenham dito que seria a segunda vez em que para lá se dirigia.

Marcos confessa a prática do crime de tráfico de drogas.

Foram encontrados no terreno baldio 46 eppendorfs contendo cocaína, com peso bruto de 50,5g e maconha, em 14 porções, com peso de 45,7g, todas embaladas e prontas para comercialização.

O modo de execução narrado pelos policiais encontra-se em sintonia com a prática de outros delitos de igual natureza nesta comarca. Sempre se identifica um agente que recolhe e entrega a droga, que é mantida escondida em local diverso de onde os agentes se posicionam, enquanto outro recebe o dinheiro, como forma de evitar a investigação e confirmação da prática do delito. Também é característica do delito a ausência de manutenção da droga em poder de quem comercializa, esta sempre permanece armazenada em pequenas quantidades em local distinto, sempre a evitar a investigação e, mais importante, a perda da mercadoria.

Não há nestes autos elementos para se acreditar que os policiais quisessem prejudicar os réus, ou que seu relato não fosse digno de confiança.

É bem verdade que a palavra dos policiais na fase inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não está sujeita às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o inquérito policial de procedimento meramente informativo. Todavia, não menos verdade é que, no caso em exame, os policiais foram

ouvidos em juízo e, nesta oportunidade, cuidou-se de observar todas as garantias inerentes ao devido processo legal.

Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. (TJSP APL 0015621-05.2004.8.26.0032 SP 0015621-05.2004.8.26.0032. Órgão Julgador 3ª Câmara de Direito Criminal; Publicação 08/03/2017; Julgamento 7 de Março de 2017; Relator Airton Vieira)

Assim, há que se reconhecer a segurança e a fidedignidade dos depoimentos policiais, a sustentar a acusação.

A prova, portanto, é robusta, a despeito da negativa dos réus Gustavo, Michael e Roberto Túlio. Não é imprescindível que com eles tenha sido encontrada a droga para que o crime esteja configurado. Ademais, os depoimentos testemunhas confirmaram que todos se revezaram na comercialização e no recolhimento da droga.

Há uma diferença entre a foto (momento da abordagem) e o filme (dinâmica dos fatos). Quando os réus são abordados, apenas um recorte temporal está presente. Contudo, considerando que fora realizada campanha por temo relevante, outros detalhes foram apurados, os quais não estavam presentes no momento da prisão, mas que a justificaram e foram revelados nos autos.

Neste diapasão, a versão de Michael não prospera, tampouco a gravação intempestivamente apresentada por este. Esta, realizada no meio da rua, confirma a versão dos policiais, que o abordaram antes de chegar no terreno baldio, após ele ter ido a primeira vez no local e após a prisão de Marcos.

A escolha do procedimento policial, momento da prisão e apreensão ou não de usuário de drogas, não invalida a investigação, ao contrário, trata-se de decisões que precisam ser tomadas de forma imediata com maior aptidão para o esclarecimento dos fatos e confirmação da prática dos crimes. Assim, justifica-se, inclusive, a ausência de prisão dos usuários, não sendo esta imprescindível para a confirmação do delito. Outrossim, os usuários costumeiramente mantêm-se silentes para evitar represálias ao imputar a comercialização a determinados agentes. Logo, a prisão dos usuários não é requisito para a prática do delito.

Observo que não é caso de reconhecer a figura do tráfico privilegiado. Todos os réus possuem condenações pela prática do crime de tráfico de drogas em momento anterior, o que revela que estes se dedicam a atividades criminosas, não sendo primários e não possuindo bons antecedentes. Logo, os requisitos do art. 33, §4º, não estão presentes.

Em relação ao réu Roberto Túlio chama atenção as conversas extraídas de seu celular, dando conta da prática de atos reiterados de comercialização de entorpecentes, com lista de devedores, combinação de aquisição e entrega da droga. O mesmo é possível dizer em relação a Michael, tendo havido extração de mensagens de seu celular indicando a comercialização da droga em momento pretérito.

Neste diapasão, a prova dos autos é segura e permite a condenação dos réus pela prática do crime de tráfico de drogas.

Quanto ao crime de associação para o tráfico, dos depoimentos e dos dados extraídos dos celulares não se permite confirmar a prática do delito.

Não há prova da estabilidade e da permanência na prática da traficância capaz de indicar que os réus Roberto Túlio e Michael se encontravam associados, considerando que a Representante do Ministério Público pugnou pela absolvição dos demais em relação a este crime.

Consigno que as mensagens contidas no celular de Michael apenas confirmam a

aquisição da droga e a venda para usuários, não se extraindo que este estava associado com mais algum agente, de forma estável e permanente, para a prática do crime de tráfico de drogas.

Em relação a Roberto Túlio há indícios, os quais não foram convertidos em prova. Extraí-se das mensagens contidas no seu celular conversas importantes empreendidas entre ele e sua namorada (que não foi identificada, embora fosse possível) que aponta para uma possível posição de comando de Roberto em relação ao grupo. Também há referência a Vanessa, que teria entrado em contato com o taxista Juliano para buscar o réu em um ponto de venda de drogas, que possivelmente poderia contribuir com as investigações, o que também não ocorreu. O próprio celular da namorada do réu poderia conter mais informações que atestassem a associação para o tráfico, não tendo recebido atenção. As conversas empreendidas com outros interlocutores não permitem concluir que haveria associação com estes ou se seriam apenas fornecedores eventuais.

A prova dos autos não permite identificar os elementos de permanência e estabilidade na associação para o tráfico dos réus em relação a outros agentes. Logo, a imputação quanto ao crime de associação para o tráfico não merece prosperar.

Neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E DE PERMANÊNCIA NO DELITO DO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A DEDICAÇÃO DO AGENTE EM ATIVIDADES CRIMINOSAS. APLICABILIDADE. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MODO SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

2. Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o vínculo subjetivo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n.

11.343/2006.

3. In casu, à mingua de um exame aprofundado do conteúdo probatório, verifica-se que a Corte de origem não apresentou elementos concretos que demonstrem efetivamente o vínculo associativo estável e permanente entre o paciente, o menor apreendido e a facção criminosa local. Na falta de comprovação do vínculo subjetivo entre os agentes no cometimento do delito de associação para o tráfico, a absolvição do paciente é medida que se impõe.

4. Nos termos do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

5. Caso em que o réu foi absolvido pela prática do delito de associação para o tráfico, não sendo a quantidade dos entorpecentes apreendida suficiente para inferir, por si só, a sua dedicação ao

tráfico de entorpecentes. Aplicação da causa de diminuição no patamar máximo.

6. Embora o paciente seja primário e a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos, o regime semiaberto é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, quando desfavoráveis as circunstâncias judiciais (art. 33, §§ 2º e 3º, e art. 59, ambos do CP).

7. Não se mostra recomendável o deferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, diante da aferição desfavorável da quantia e da espécie das substâncias apreendidas (art. 44, III, do CP).

8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para aplicar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 2/3, resultando a pena final em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, mais pagamento de 194 dias-multa, no

regime inicial semiaberto.

(HC 516.811/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO DURADOURO ESTÁVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É imperioso assinalar que "[a] jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei n. 11.343/2006) exige a demonstração do elemento subjetivo do tipo específico, qual seja, o ânimo de associação de caráter duradouro e estável. Do contrário, o caso é de mero concurso de pessoas" (HC n. 482.028/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 19/2/2019).

2. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram a participação do agravante em um dos diversos núcleos integrantes da estrutura hierárquica da associação criminosa em exame, o qual seria responsável pela em vareja da droga apreendida, o que evidencia o elemento subjetivo do tipo penal, de modo que infirmar a conclusão a que elas chegaram implicaria indevida dilação probatória.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 500.927/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019)

Portanto, a denúncia quanto ao crime de associação para o tráfico não merece prosperar.

Advirto que não é possível determinar a fixação no regime inicial fechado independentemente do quantum da pena, em atenção ao TEMA 972 firmado em Repercussão Geral pelo STF.

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, § 1º, da LEI 8.072/1990. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal. 2. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido. (ARE 1052700 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 02/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018 )

Portanto, a fixação do regime dependerá do quantum da pena fixado e das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59, III, do Código Penal. Ausentes causas de exclusão da ilicitude. Os acusados eram, na data dos fatos, imputáveis, tinham plena consciência da ilicitude de sua conduta, sendo-lhes exigível conduta diversa. Portanto, culpáveis.

A prova é certa, segura e não deixam dúvidas da condenação pela prática do delito de tráfico, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

DOSIMETRIA

Em razão disso, passo à dosimetria da pena nos termos do artigo 68 do código penal, fixando conforme preceituado pelo artigo 59 do CP, fazendo-a de forma individualizada.

DO RÉU MICHAEL FELIPE DE MORAIS

Primeira etapa. A culpabilidade é normal a espécie. Não há maus antecedentes a serem valorados, porquanto só haja uma condenação anterior que será avaliada como

reincidência. Não há nos autos elementos para valorar a conduta social e personalidade. Os motivos, circunstâncias e as consequências são normais a espécie. A natureza da substância e a quantidade de droga não justificam maior exasperação. Não há comportamento da vítima a ser valorado.

Fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Segunda etapa. O réu é reincidente. Identifico a presença da atenuante da menoridade relativa.

Diante disto, fixo a pena intermediária em 5 anos e 5 meses de reclusão e 541 dias-multa.

Terceira etapa. Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena.

Torno definitiva a pena de 5 anos e 5 meses de reclusão e 541 dias-multa.

Regime inicial de cumprimento: FECHADO

Diante do montante da pena arbitrada, além de ser o réu reincidente, determino seu cumprimento inicial no regime fechado, nos termos do artigo 33, §2º, a e b, do CP. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): IMPOSSIBILIDADE

Inviável o benefício da substituição, tendo em vista o montante de pena aplicado.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela

Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Não há elementos suficientes para a detração.

#### DO RÉU ROBERTO TULIO RODRIGUES FERREIRA

Primeira etapa. A culpabilidade é normal a espécie. Há maus antecedentes a serem valorados, processo n. 1500541-33.2019.8.26.0538 e 1500409-73.2019.8.26.0538. Não há nos autos elementos para valorar a conduta social e personalidade. Os motivos, circunstâncias e as consequências são normais a espécie. A natureza da substância e a quantidade de droga não justificam maior exasperação. Não há comportamento da vítima a ser valorado.

Fixo a pena base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Segunda etapa. O réu é reincidente específico, processo n. 1500214-25.2018.8.26.0538.

Diante disto, fixo a pena intermediária em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Terceira etapa. Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena.

Torno definitiva a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Regime inicial de cumprimento: FECHADO

Diante do montante da pena arbitrada, além de ser o réu reincidente, determino seu cumprimento inicial no regime fechado, nos termos do artigo 33, §2º, a e b, do CP. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): IMPOSSIBILIDADE

Inviável o benefício da substituição, tendo em vista o montante de pena aplicado.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela

Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Não há elementos suficientes para a detração.

#### DO RÉU GUSTAVO NATAN DONIZETTI VIEIRA

Primeira etapa. A culpabilidade é normal a espécie. Há maus antecedentes a serem valorados, processos n. 1500171-83.2020.8.26.0614 e 1500363-79.2021.8.26.0614. Não há nos autos elementos para valorar a conduta social e personalidade. Os motivos, circunstâncias e as consequências são normais a espécie. A natureza da substância e a quantidade de droga não justificam maior exasperação. Não há comportamento da vítima a ser valorado.

Fixo a pena base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Segunda etapa. O réu era menor de 21 anos na data do fato, portanto, presente a atenuante da menoridade relativa.

Diante disto, fixo a pena intermediária em 5 anos 1 mês e 7 dias de reclusão e 510 dias-multa.

Terceira etapa. Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena.

Torno definitiva a pena de 5 anos 1 mês e 7 dias de reclusão e 510 dias-multa.

Regime inicial de cumprimento: FECHADO

Diante do montante da pena arbitrada, além de ter o réu condenação anterior pela prática do mesmo delito, consistindo em circunstância judicial negativa, determino seu cumprimento inicial no regime fechado, nos termos do artigo 33, §2º, a e b, do CP.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): IMPOSSIBILIDADE

Inviável o benefício da substituição, tendo em vista o montante de pena aplicado.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-

mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela

Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Não há elementos suficientes para a detração.

#### DO RÉU MARCOS ADRIANO VICK

Primeira etapa. A culpabilidade é normal a espécie. Há maus antecedentes a serem valorados, processo n. 1500032-71.2019.8.26.0613. Não há nos autos elementos para valorar a conduta social e personalidade. Os motivos, circunstâncias e as consequências são normais a espécie. A natureza da substância e a quantidade de droga não justificam maior exasperação. Não há comportamento da vítima a ser valorado.

Fixo a pena base em 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa.

Segunda etapa. Presente a atenuante da confissão espontânea.

Diante disto, fixo a pena intermediária em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Terceira etapa. Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena.

Torno definitiva a pena de 5 anos e 500 dias-multa.

Regime inicial de cumprimento: FECHADO

Diante do montante da pena arbitrada, considerando a circunstancia judicial negativa dos maus antecedentes, notadamente porquanto se trate de condenação anterior pela prática do mesmo crime, determino seu cumprimento inicial no regime fechado.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): IMPOSSIBILIDADE

Inviável o benefício da substituição, tendo em vista o montante de pena aplicado.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-

mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela

Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Não há elementos suficientes para a detração.

#### DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR os réus pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, atribuindo a pena de 5 anos e 5 meses de reclusão em regime inicial fechado e 541 dias-multa a MICHAEL FELIPE DE MORAIS; 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado e 680 dias-multa a ROBERTO TULIO RODRIGUES FERREIRA; 5 anos 1 mês e 7 dias de reclusão em regime inicial fechado e 510 dias-multa a GUSTAVO NATAN DONIZETTI VIEIRA; e 5 anos de reclusão em regime inicial

fechado e 500 dias-multa a MARCOS ADRIANO VICK.

Diante do montante da pena aplicada, mantida as razões que justificaram a sua prisão preventiva, portanto, não tem o direito de apelar em liberdade. De fato, tendo os respondido ao processo preso, seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que o condenou a pena de cinco anos em regime fechado.

No mais, as circunstâncias do caso concreto, demonstram o risco de reiteração criminosa caso revogada a prisão preventiva, conforme já ocorreu no passado, quando respondiam aos crimes anteriores.

Assim, revisando a prisão preventiva dos réus, entendo pela permanência dos fundamentos que a justificaram.

Fica, assim, recomendado na prisão em que se encontra.

Decreto a perda dos bens apreendidos em favor da União. Proceda-se na forma do art. 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06.

Caso ainda não tenha sido feito, fica autorizada a destruição da droga apreendida, com exceção de 0,2 gramas de cada substância, quantidade que ficará reservada para eventual contraprova. A quantidade reservada para contraprova deverá ser incinerada após o trânsito em julgado deste feito.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio. Se necessário, expeça certidão de honorários.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

Tambaú, 03 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA